

1500667-55.2022.8.26.0481

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500667-55.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500667-55.2022.8.26.0481 - Feito nº 2022/001951

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALITA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2208132/2022, ofereceu denúncia em face de TALITA SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificada às fls. 24, dos autos deste processo crime, dando-a como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 01/08/2022, às 23 horas, na Rodovia SP 270, km 648, nessa cidade e Comarca, TALITA SILVA DOS SANTOS estaria transportando, para entrega a consumo de terceiros, 12 porções de haxixe, pesando aproximadamente 1590,00 gramas, e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 1,2 grama, drogas capazes de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar. Consta, por fim, que o delito teria sido cometido no interior de um ônibus de passageiros da "viação Motta" e que os entorpecentes estariam sendo transportados do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo.

Realizada audiência de custódia virtual, nos termos do Provimento CSM nº 2.629/2021, após a entrevista da autuada e manifestação do ilustre representante do Ministério Público e da nobre Defesa, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual foi substituída por prisão domiciliar na data de 02/08/2022 (fls. 57-66).

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (fls. 123-125 e 126-128).

A acusada constituiu novo advogado (fls. 169) e ofertou defesa prévia (fls. 158-160).

A denúncia foi recebida em 25/10/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária e, com fundamento no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, que autorizou a realização das audiências por videoconferência ou mistas em todas as matérias, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 193-197).

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, com a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, foi revisada e mantida a prisão domiciliar da acusada em 26/10/2022 (fls. 201-203).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, sendo a ré, ao final, interrogada.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação da ré, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A defesa pugnou pela absolvição da acusada e, subsidiariamente, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de TALITA SILVA DOS SANTOS pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 33, caput, e artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/2006.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante da ré (fls. 04-05), boletim de ocorrência (fls. 06-09), auto de exibição e apreensão (fls. 28-29), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 26-27) e laudos pericial químico de entorpecente (fls. 123-125 e 126-128), que atestou que a substância encontrada se tratava de cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), que é de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída à acusada TALITA SILVA DOS SANTOS.

Inquirida, a testemunha JEFFERSON JOSÉ COIMBRA, policial militar, relatou que "Sim, senhora. Nós estávamos em frente da base operacional do município de Epiácio desenvolvendo operação 'Divisas Integradas' para combater o tráfico de drogas. Interceptamos este ônibus leito, interestadual, que fazia o trajeto Ponta Porã - São Paulo. Talvez porque houvesse várias viaturas no local, inclusive do BAEP, percebi o nervosismo de Talita, que, inclusive, estava sentada em uma poltrona bagunçada, com várias espumas. O travesseiro dela estava rasgado, mas não havia nada no interior. Tampouco havia drogas no assento do ônibus. Ela tomava tererê e eu desconfiei das dimensões da garrafa, seu peso era unusual. Por isso, pedi que ela descesse do ônibus e percebi que a garrafa estava recheada de haxixe. Ela confessou que tinha recebido a proposta de tráfico ainda em São Paulo, de um rapaz chamado Júnior. Em seguida, viajou até Coronel Sapucaia, pegou a drogas de um rapaz chamado Thiago, receberia R\$ 1.500,00 pelo transporte e deveria entregá-la em São Paulo para terceiro chamado João. Só me lembro do haxixe, 1.560 gramas".

No mesmo sentido, o também policial militar ABRAHÃO CARVALHO BOTURA complementou "Em fiscalização de rotina abordamos o ônibus da Viação Mota. Em entrevista, Talita demonstrava inexplicável nervosismo, não justificava razoavelmente as razões da viagem, razão pela qual fizemos uma vistoria mais minuciosa. Na garrafa que ela levava em mãos havia drogas, haxixe, depositadas não em seu interior propriamente dito, mas na parte entre a capa e o final do recipiente. Ela confessou que tinha recebido a proposta de tráfico ainda em São Paulo, de um rapaz chamado Júnior. Em seguida, viajou até Coronel Sapucaia, pegou a drogas de um rapaz chamado Thiago, receberia R\$ 1.500,00 pelo transporte e deveria entregá-la em São Paulo para terceiro chamado João. Só me lembro do haxixe, 1.560 gramas".

Interrogada, a acusada TALITA SILVA DOS SANTOS confessou a prática delitiva, dizendo que "Na verdade, me fizeram a proposta de buscar um chá e eu estava precisando muito, enfrentava um momento de dificuldade, queria pagar o aluguel e comprar algumas coisas para minha casa, porque tenho dois filhos, não justificando

meu erro, foi num momento de desespero meu, mas acabei me complicando mais. Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra da acusada se encontra em consonância com o conjunto probatório, em especial das testemunhas policiais militares que empreenderam as investigações e efetuaram a diligência de apreensão das substâncias.

Inicialmente, não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Todavia, vale consignar que "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância", nos moldes delineados do artigo 197 do Código de Processo Penal.

De outro lado, por tudo que foi coligido durante a persecução criminal, revelou-se inarredável coerência entre as palavras da acusada e as demais provas amealhadas. Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, consigno que resultou devidamente caracterizada, visto que a prova oral colhida é harmônica e convincente no sentido de que efetivamente a ré foi presa enquanto transportava entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Quanto à causa de aumento do inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06, entendo que o fato da ré utilizar meio de transporte público para transportar a droga não implica a causa de aumento de pena, uma vez que a causa de aumento de pena se aplica apenas caso a comercialização ocorra dentro do transporte público, o que não é o caso dos autos.

Nesse aspecto:

"TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA DE AUMENTO - TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga." (STF - HC: 122042, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017).

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a grande quantidade de entorpecente e o modo de acondicionamento (12 porções de haxixe, pesando aproximadamente 1.590,00 gramas, capazes de gerar, ao menos, 795 porções individuais, considerando que uma porção de haxixe contém, em média, de um a dois gramas, além de uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 1,2 grama); a tentativa de ocultação do entorpecente (as porções de haxixe encontravam-se ocultadas no interior de uma garrafa térmica); a questionável origem financeira dos valores apreendidos (R\$ 119,00, em notas trocadas), eis que nenhuma prova idônea foi trazida aos autos para comprovar sua licitude; o local onde se deu a apreensão dos entorpecentes (divisa dos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, conhecida rota de tráfico de entorpecentes oriundos do Paraguai, no interior de transporte público coletivo); o nervosismo, bem como as respostas vagas apresentadas pela acusada ao ser entrevistada pelos policiais militares; e a confissão informal da ré aos policiais que a prenderam, reiterada em juízo, sob o crivo do contraditório, revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de

legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis. Isso porque deixo de considerar, nesta fase de dosimetria, a fim de evitar "*bis in idem*", os critérios constantes do artigo 42, da Lei de 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias serão consideradas na terceira fase de dosimetria.

Nesse sentido:

"[...] a Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, ainda, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza, o *bis in idem*. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder de discricionariedade, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de *bis in idem*" (STF – HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: Dje-213 DIVULG 29-10-2014).

Destarte, considerando que não ostenta a ré maus antecedentes criminais e que todos os demais elementos são inerentes ao tipo penal, fixo as penas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP). No entanto, mantenho as penas anteriormente fixadas, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado, conforme já exarado, o cometimento do delito entre Estados da Federação. Assim, aumento em 1/6 as penas, obtendo-se, como resultado, o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Por outro lado, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa. No entanto, considerando a quantidade de entorpecente apreendida reputo adequada uma redução no montante de 1/2, resultando-se no total de 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Nesse sentido:

"É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017, Dje 17/4/2017).

"Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de 'mula' do tráfico. Inicialmente, convém anotar que a Quinta e a Sexta Turmas deste Superior Tribunal de Justiça têm entendimento oscilante sobre a matéria. Diante da jurisprudência hesitante desta Corte, entende-se por bem acolher e acompanhar o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a simples atuação como "mula" não induz automaticamente a conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a "mula" integre a organização criminosa (HC 132.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 13/2/2017). Ainda sobre a matéria, firmou-se também no Pretório Excelso o

entendimento de que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, configura circunstância concreta e idônea para se valorar negativamente na terceira fase da dosimetria, modulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (HC 120.985, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/6/2016). Logo, devidamente comprovado que a conduta do paciente se reveste de maior grau de reprovabilidade, pois tinha conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal. (HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 6/4/2017, DJe 17/4/2017). Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, excepcionalmente, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada à ré, da primariedade, conduta social, personalidade favoráveis e, ainda, por ter confessado integralmente a prática delitiva e ter mostrado grande arrependimento, não obstante a alta quantidade de entorpecentes apreendidos.

E, pelos mesmos motivos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade e à razão de uma hora por dia de condenação; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser corrigida monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR TALITA SILVA DOS SANTOS, já qualificada nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário-mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas; e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privação de liberdade; e prestação pecuniária em favor de instituição pública ou privada de destinação social no montante de um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente, a partir da data dos fatos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à época da execução.

Considerando o regime inicial fixado e que não mais estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar da acusada (ausência de periculosidade atual, encerramento da fase de instrução, residência fixa, ocupação lícita e primariedade), concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se, desde logo, o competente alvará de soltura clausulado.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Concedo ao sentenciado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa, no prazo de 10(dez) dias.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$ 119,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 28), nos moldes do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 63, § 1º, da lei 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento dos valores (depósito judicial às fls. 84) em favor da União e o seu encaminhamento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude dos fundamentos utilizados nesta sentença.

Considerando que foram apreendidos nos autos uma garrafa térmica (auto de exibição e apreensão de fls. 28), o qual está diretamente relacionado à prática delitiva, declaro o seu perdimento em favor da União e autorizo a destruição do bem, dada à inexpressividade de seu valor econômico.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º e § 2º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação da ré.

Intime-se o(a) acusado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada, contudo, a regra prevista no art. 98, § 3º, do CPC, no prazo de 10(dez) dias.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 23 de novembro de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.